

争法》及其司法解释的相关规定,《中华人民共和国反不正当竞争法》系知识产权专门法的有限补充,适用互联网专条必须满足第十二条第二款的“利用技术手段妨碍、破坏”的行为模式,否则应当适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第二章其他条款,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条系原则性兜底条款,因此涉互联网行为的法律规制条款的适用顺序应当为:知识产权专门法—《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第一项至第三项—《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第四项—《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条至第十一条—《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条。本案裁判系在发现原告产品运行原理、详细解构被控行为的运行过程的基础上,提出适用互联网专条兜底条款。

二、互联网专条兜底条款的具体适用条件

第一,在主体上,双方系具有竞争关系的经营者。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》解释第二条,“其他经营者”系与经营者在生产经营活动中存在可能的争夺交易机会、损害竞争优势等关系的市场主体。故《中华人民共和国反不正当竞争法》的适用并非不再考量而是拓宽了对竞争关系的理解,即不再限于传统经济下同一市场中利益此消彼长这类直观的竞争关系,而是将对交易机会争夺的可能性、对竞争优势损害的可能性等均纳入考量因素。本案中,被告的产品可以替代下载和连接“××A Carlife”APP手机端或者内置“××A Carlife”手机端,即能实现车机互联的功能,与原告的产品存在交易机会的争夺,故应认定双方存在竞争关系。

第二,在行为方式上,被控行为利用了技术手段。

对技术手段的解释,直接影响到兜底条款的适用范围。根据体系解释,兜底条款应当比照前三项的共性作出一定限缩,故此处的“技术手段”应当指直接针对其他经营者的产品或者服务产生技术效果的手段。本案中,被告产品的实现必须利用车机端、手机端的通信协议,而获取通讯协议的方式需要通过技术手段进行,而技术手段的实施有碍于网络数据传输,故最终认定被告使用了技术手段。

第三，在行为结果上，被控行为妨碍、破坏了其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

利益的争夺和消长属市场规律之下的常态，司法裁判需要谨慎对待新技术新业态，故行为的失当性才是考量的重点，而这需要综合考量。一是考量被告的行为是否造成原告的产品或服务销量减少、评价变差、流量等无形利益被分享。二是考量被告的行为是否经过原告许可或者符合行业惯例。三是考量被告的行为是否影响了用户的选择，降低原告产品或服务的竞争力。本案中，被告行为失当的根源在于其产品获利点“破坏”原告车机端和手机端的通信，影响了原告产品的正常运行，使其发展升级受阻，甚至损害消费者利益。

第四，主观意图上，经营者对其行为存在故意。

主观故意并非仅仅指对损害后果的积极态度，还应当包括以获利为目的，对他人利益受损后果持放任态度的间接故意。主观意图的认定需要结合证据外观来推定。本案中，被告通过破坏手机端、车机端之间的通信来实现自己产品的应用，以获取经济利益，且被告产品无法离开原告平台，其对于产品运行方式和后果是明知的，故应认定被告主观上具有故意。

本案裁判厘清了法律适用顺位和具体适用要件，将具体行为与智能车载系统领域这一新兴产业的特点和价值、消费者利益等相结合进行法律评价，通过互联网专条兜底条款实现了对互联网领域多样化竞争形态的有效规制，以增加开发者信心，鼓励和保护技术创新。

编写人：北京知识产权法院 黄秋平

北京市西城区人民法院 高天

网络直播语境下商业诋毁行为的司法认定

——义乌市甲商贸有限公司诉义乌市乙电子商务商行、
义乌市丙家居用品有限公司不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省金华市中级人民法院(2022)浙07民终4841号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):义乌市甲商贸有限公司

被告(上诉人):义乌市丙家居用品有限公司

被告:义乌市乙电子商务商行

【基本案情】

义乌市甲商贸有限公司运营抖音账号“甲饰品”。2022年2月,义乌市乙电子商务商行的某电商平台粉丝群内,该群群主及粉丝多次发布“甲饰品”直播间相关信息,群主“××A diy 美甲饰品配件分享”发表了“毕竟他们老板因为卖假货现在还在缓刑面壁思过,判了一年半”“卖假货甲油胶被判了一年半”等言论。该群当时的群成员为500人。2022年2月15日晚至16日凌晨,义乌市乙电子商务商行的某电商平台账号“××A diy 美甲饰品配件分享”在某电商平台直播过程中,当粉丝提及“甲饰品”时,义乌市丙家居用品有限公司的法定代表人童某予以回应并发表以下言论:“他们老板开假营销工厂,卖假货被抓了,判了一年半,现在还在缓刑,面壁思过”“缓刑一年半,因为卖假货,

货值20多万元”“但是我们保底只能200,他们是保底300,因为他们放了很多很多小不溜秋的,没用的”等。当晚直播时粉丝数量为几百人。

【案件焦点】

二被告在某电商平台粉丝群及某电商平台直播间内的行为是否构成对原告的商业诋毁。

【法院裁判要旨】

浙江省义乌市人民法院经审理认为:二被告在某电商平台粉丝群及某电商平台直播间内多次向消费者强调义乌市甲商贸有限公司负责人因卖假货被判刑,意在贬损竞争对手的产品品质,进而引导消费者购买自家的产品。同时,二被告未提供证据证明义乌市甲商贸有限公司法定代表人或负责人因刑事案件被处罚,上述言论明显属于虚假信息。二被告的上述行为系主观故意而为之,且该涉及刑事犯罪的言论系严重影响商誉的陈述,足以误导消费者对原告资信状况、经营能力、经营状况、商品质量的认知,影响消费者对原告公司的整体评价,从而影响消费者的选择,损害原告的商业信誉、商品商誉,属于反不正当竞争法所规制的商业诋毁行为,二被告应承担赔偿责任并就其商业诋毁行为为义乌市甲商贸有限公司消除影响。

浙江省义乌市人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》(2019修正)第二条、第十一条、第十七条之规定,判决如下:

一、被告义乌市乙电子商务商行(经营者:祝甲)、义乌市丙家居用品有限公司于本判决生效之日起十五日内在抖音账号“××A diy美甲饰品配件分享”直播间上连续七天刊登声明,为原告义乌市甲商贸有限公司消除影响;

二、被告义乌市乙电子商务商行(经营者:祝甲)、义乌市丙家居用品有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告义乌市甲商贸有限公司经济损失30000元(含合理费用);

三、驳回原告义乌市甲商贸有限公司的其他诉讼请求。

义乌市丙家居用品有限公司不服一审判决,提起上诉。

浙江省金华市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：
驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、《中华人民共和国反不正当竞争法》中“商业诋毁”行为的定义

商业诋毁是经营者为了损害他人利益或增加自身经济利益，所开展的损害他人商品声誉、商业信誉的一种不正当竞争行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条中亦对商业诋毁行为进行了厘定，商业诋毁是指经营者编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手商业信誉和商品声誉的行为。开展商业诋毁，其目的在于削弱竞争对手的市场竞争力以此来为自己谋取不正当利益。其行为主要有两种表现形式：其一是恶意编造虚假信息或误导性信息，加以传播，减弱竞争对手跟自己角逐的能力；其二是利用现存的虚假信息或误导性信息，扩大信息影响力，进而为己方谋取不正当利益。

网络直播语境下商业诋毁行为并非网络环境下所生发出的全新产物，而是网络不正当竞争的表现形式，是传统不正当竞争行为在互联网维度的扩展或延伸。这一内涵也解释了网络商业诋毁的行为本质，其既非完全突破传统不正当竞争行为的“创新”，也并非“传统商业诋毁”。究其缘由，伴随着数字化、技术化的改革，网络空间的边界开始蔓延，越来越多的主体参与进网络空间的交互中。依托强大的技术支持，网络空间已然成为网民“发声”“交往”乃至开展商业活动的重要场域。直播中商业诋毁行为诞生于网络空间，依托于信息技术，并由此产生了区别于传统商业诋毁行为的特点。

二、网络直播语境下商业诋毁行为的特殊性

一是诋毁对象的隐匿性。商业诋毁的本质即于不当贬损竞争对手的商誉，进而为己方赢得更多的市场份额，攫取商业利益，其中必要的环节即在于明确的诋毁对象。在传统的商业诋毁模式中，一般由侵权企业直接或间接实施，主要表现为在报纸、新闻、广告等媒介中谩骂或诽谤竞争对手，损害其声誉。基于该特定的诋毁手段，为行为人单方的输出行为，具有

单向性，加之言论的影响具有一定的地域限定、时间限定、成本限制，诋毁者为达成目的，必须对特

定对象加以明确,否则难以达到“一击即中”的效果。而在网络空间,特别是直播的过程中的诋毁对象却并不一定如此明确表达,反而具有一定的隐匿性。原因在于,网络直播的受众并不拘泥于特定的地域、特定的时间,成本较低,且直播过程中往往主播与观众、观众相互之间交互性强,沟通的效率显著提高,往往不必指名道姓,可通过手势、表情、言语,甚至借助直播间观众,即可达成暗示特定诋毁对象的效果。心理暗示所形成的效果甚至明示,更易引发受众的关注形成记忆点。

二是诋毁行为的即时性。传统商业诋毁行为的载体多为报刊、电视、广播等媒体频道,其传播的方式往往是“自上而下”“由点到面”的中心扩散式。依托于信息技术的发展,原有的“自上而下”的信息传播方式发生了革命性的变革。社会交往从科层制转变为高度扁平化的空间,剥离了前者对信息交流传播的重重阻碍,具有高度的及时性、共享性、多媒体性。得益于此,话语能够在此间更加自由、快速地传播,网络信息传播的时间更快、影响更广、范围更大。在扁平的网络空间中,场域开放,渠道广泛、沟通成本低、流动性强。仰赖于此,网络直播中,无数的主体可以随时随地地通过网络进行交互,商业诋毁行为可以随时随地地发生。更因行为发生的瞬时性,取证难度较传统模式而言更大。

三是诋毁影响的严重性。发生在网络直播背景下的诋毁行为往往影响远大于传统商业诋毁行为。诋毁所造成的影响难以逆转,特别是身处网络舆论环境中的市场主体,商誉毁损只需要一瞬。而刻板印象一旦形成,便堕入了“塔西佗陷阱”。一方面,网络的丰富性、低成本性不断地分散受众的注意力,存在即使澄清也无人在意的情况;另一方面,基于网络的流变性,网络用户往往在短时间内进行大规模的浏览“迁徙”,直播间的观众,也往往在多个直播间中反复浏览,多次选择,产生误解的受众往往并非商誉澄清内容的受众。由此,低注意力附加高刻板印象、高流动性,使得网络环境中的商誉“生长”的“生态环境”极其脆弱,一旦被摧毁,挽回商誉便沦为“高成本、低效率”的非理性选择。

